

1500765-11.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Mesmo assim, o policial falava que era de tráfico. Até que foram levados à Delegacia. Não tinha droga.

WESLEY disse que estava com o dinheiro mas negou que tivesse com a droga.as

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal de WESLEY, a movimentação externada e que motivou a abordagem policial, a tentativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500765-11.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125543/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 17797614 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1314/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2125543 - 7º Distrito Policial de Piracicaba, 1314/21/922 - 7º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 11 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor Público, Dr. André Luiz da Silva Araujo. Apresentados os acusados KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN E WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA, e as testemunhas arroladas pela defesa: Rosângela Aparecida de França, Priscila Amorim Zeffa, André Fabiano Casimiro e Carlos Henrique Zavaglia.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusados com seu defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito aos acusados a observação determinada no artigo

186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas da defesa (Rosângela, Priscila, André e Carlos) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogados os réus (Kelly e Wesley). Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA e KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso de pessoas (CP, art. 29).

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2021, por volta de 00h54min, na Rodovia do Açúcar, km 493, Jardim São Francisco, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA, qualificado e indiciado às fls. 06/07, 42/45 e 50, e KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN, qualificada e indiciada às fls. 08/09, 46/49 e 51, atuando em conluio e com unidade de desígnios delituosos, traziam consigo e transportavam, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 03 (três) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 0,7g (sete decigramas) (item 1, fls. 34/37), 17 (dezessete) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) (item 2, fls. 34/37), 21 (vinte e um) invólucros em papel alumínio contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 3,5g (três gramas e cinco decigramas) (item 3, fls. 34/37), e 05 (cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, “maconha”, com peso líquido de 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) (item 4, fls. 34/37), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, WESLEY – que de longa data se dedica ao tráfico de drogas – e KELLY transportavam e traziam consigo porções de cocaína, crack e maconha no veículo VW/GOL, placas EAS 0287/Piracicaba/SP. (Vide item 2 da cota ministerial. Inclusive, o ato infracional análogo ao crime de homicídio teria sido praticado por WESLEY em contexto de disputa por pontos de venda de drogas na cidade de Rio das Pedras/SP). No início da madrugada, imprimindo alta velocidade ao ultrapassarem uma viatura policial, foram acompanhados e abordados por policiais militares. Nas buscas, os agentes localizaram R\$ 2.210,50 (dois mil duzentos e dez reais e cinquenta centavos) no porta-luvas no veículo; no banco traseiro, dentro de uma caixa de óculos, 05 (cinco) porções de maconha, 21 (vinte e uma) de crack e 17 (dezessete) eppendorfs de cocaína.

Durante a diligência, KELLY foi revistada por policial feminina e, sob seu sutiã, localizados R\$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) e outros 05 (cinco) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles encontrados no carro (vide fotos fls. 28/30).

Informalmente, WESLEY confirmou que o dinheiro era produto do tráfico de drogas por eles praticado (fls. 04 e 05). Na delegacia, porém, ambos negaram os fatos (fls. 06/09). Por ocasião da apresentação da ocorrência à autoridade policial, KELLY foi submetida a minuciosa revista pessoal e então encontrada, sob suas vestes íntimas, mais R\$230,00 (duzentos e trinta reais). O exame pericial constatou a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto fls. 24/26 e laudo fls. 34/37).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Douglas Vitti – Policial Militar – narrou que, em patrulhamento pela Rodovia do Açúcar, teve a viatura ultrapassada por um veículo VW/Gol em alta velocidade, o que chamou a atenção da equipe e motivou a abordagem. O condutor era o réu WESLEY e a passageira era a ré KELLY. No veículo, dentro do porta-luvas, foi localizada a quantia de R\$ 2.210,50 e, no banco traseiro, atrás do banco do motorista, embaixo, uma caixa de óculos com 5 porções de maconha, 21 de crack e 17 de cocaína. A ré disse que o dinheiro lhe pertencia, mas não soube explicar a origem. Uma policial

feminina chegou e revistou a ré, encontrando no sutiã dela R\$ 1.134,00 e 5 pinos com cocaína, idênticos aos encontrados no carro. O réu WESLEY confessou que os valores encontrados seriam do tráfico de drogas e que o casal se dedicava à essa prática. Na Delegacia, pouco mais de R\$200,00 foram encontrados sob as vestes íntimas da ré.

No mesmo sentido, José Carlos Seabra Júnior – Policial Militar.

Priscila Zeffa, mãe de WESLEY e sogra de KELLY, não estava presente na ocasião dos fatos. Eles deixaram a filha na casa da declarante e depois disso não mais os viu. Eles disseram que iam embora para casa. Não sabe se eles estavam ou não com alguma coisa. Não sabe se eles estavam com dinheiro. Nada sabe sobre o envolvimento deles com drogas.

Sargento Casimiro disse que chegou ao local após os fatos e os confirmou, inclusive a apreensão de drogas e dinheiro em poder de KELLY. WESLEY disse no local que o dinheiro era do tráfico de drogas. Não houve agressão contra os réus.

Rosângela, mãe da KELLY, disse que ficou sabendo dos fatos apenas no outro dia.

Nunca soube do envolvimento deles com drogas. O dinheiro era para a ré pagar a parcela do apartamento, no valor de R\$5.800,00. O dinheiro era proveniente, R\$1000,00 porque deu para ela, R\$1.800,00 de serviços de manicure e cabelo que a ré faz, e R\$3.000,00 era da venda de uma moto por parte do réu. Tinha entregado o dinheiro para a ré na sexta feira. Eles foram abordados no dia seguinte.

KELLY confirmou que tinha dinheiro no porta-luvas do carro. Era de seu serviço e da venda de uma moto. Mesmo assim, o policial falava que era de tráfico. Até que foram levados à Delegacia. Não tinha droga.

WESLEY disse que estava com o dinheiro mas negou que tivesse com a droga.as

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal de WESLEY, a movimentação externada e que motivou a abordagem policial, a tentativa de KELLY em esconder o elevado valor em espécie – notas de valores baixos –, bem como a apreensão de considerável quantidade de cocaína, crack e maconha – incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal –, resta certo que os denunciados, conluídos, transportavam e traziam consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente

preponderando a última, de maior gravidade' (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

DA PENA:

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 68/71 e 72/77):

- WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA embora primário, ostenta diversas anotações na Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas, tendo cumprido medidas socioeducativas (certidões fls. 73/74);

Para WESLEY, não é possível a diminuição da pena com base no art. 33, p. 4º, Lei 11.343/06.

Trazia consigo, contando com a participação de KELLY, diversas e variadas porções de entorpecentes e alta quantia, o que deixa claro que este envolvimento e organização com o tráfico ultrapassa o mero e simples conceito de coautoria para um evento específico.

Parte do dinheiro e das drogas estava no carro. A outra parte, escondida sob o sutiã da ré, o que demonstra também intensa e efetiva participação desta nos fatos. Ademais, WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA tem envolvimento com práticas infracionais graves, o que afasta ainda mais o direito ao benefício do art. 33, p. 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho benefício aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em

que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

- KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN é primária.

E não é possível indicar, pelo que foi produzido, quanto a ré estava envolvida no tráfico.

Possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, reconheceu que o chamado " tráfico privilegiado de drogas" não tem natureza hedionda.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento da Corte Superior e cancelo a Súmula 512.

Com isso, entendo possível, no presente caso, acompanhando o posicionamento das Cortes Superiores, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direitos.

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação penal nos termos da inicial.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, a improcedência da pretensão acusatória é medida que se impõe. Imputa-se aos réus a prática de tráfico de drogas.

Narra a inicial acusatória que em síntese que o veículo conduzido pelos acusados acelerou ao passar pela viatura policial, ensejando a abordagem. Que " os agentes localizaram R\$ 2.210,50 (dois mil duzentos e dez reais e cinquenta centavos) no porta-luvas no veículo; no banco traseiro, dentro de uma caixa de óculos, 05 (cinco) porções de maconha, 21 (vinte e uma) de crack e 17 (dezesete) eppendorfs de cocaína. Durante a diligência, KELLY foi revistada por policial feminina e, sob seu sutiã, localizados R\$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais)e outros 05 (cinco) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles encontrados no carro" (fls. 140-142). Wesley teria informalmente confessado os fatos.

Na fase de inquérito policial, o réu Wesley disse que : " Que, indagado se estava machucado ou se havia sido agredido por qualquer agente, informou que, durante a ação policial, o Sgt. Casemiro lhe desferiu um soco no peito, do qual não resultou lesão. Que, estando com sua esposa na sala de espera desta delegacia de polícia, o mesmo policial desferiu um soco no rosto da indiciada, não havendo quaisquer marcas ou resquícios de tal violência. Que, no tocante aos fatos que lhe são imputados, estava, na data e horário dos fatos, trafegando com seu automóvel, na companhia de sua esposa, quando recebeu ordem de parada da Polícia Militar, à qual prontamente atendeu. Que, abordados, nada de ilícito foi encontrado consigo ou com sua esposa. Que os PMS apenas encontraram uma certa quantia de dinheiro no console do seu automóvel. Que não sabe precisar a quantia encontrada, sendo certo que lá havia pouco mais de R\$ 2 mil resultantes da venda de uma motocicleta de sua propriedade, ocorrida na data de hoje, e, ainda, mais algumas centenas de reais provenientes da venda de lingerie realizada pela sua esposa. Que não havia drogas no automóvel, tampouco com a sua mulher. Que drogas foram postas no veículo pelos próprios policiais militares. Que durante a ação foi separado de sua esposa e pressionado a confessar a prática do tráfico. Que desconhece as razões pelas quais a PM forjou o flagrante. Que é autônomo. Que nunca foi preso".

A corré Kelly disse que : “ Que, indagada se estava machucada ou se havia sido agredida por qualquer agente, informou que, estando na sala de espera desta delegacia de polícia, o Sgt. Casemiro desferiu um soco em seu rosto, sem, contudo, deixar marcas ou lesões. Que, no tocante aos fatos que lhe são imputados, informa que, na data e horário dos fatos, estava com seu esposo quando receberam ordem de parada da Polícia Militar, à qual foi prontamente por ele atendida. Que, abordados, nada de ilícito foi encontrado consigo ou com seu marido. Que os PMs apenas encontraram uma certa quantia de dinheiro no porta-luvas do automóvel. Que ela própria indicou aos militares a existência de tais valores. Que não sabe precisar a quantia encontrada, sendo certo que lá havia pouco mais de R\$ 2 mil resultantes da venda de uma motocicleta pelo seu marido e, ainda, mais algumas centenas de reais provenientes de serviços de estética por ela realizados. Que não trazia drogas consigo, tampouco havia entorpecentes no automóvel. Que as drogas foram postas no veículo pelos próprios policiais militares. Que acompanhou as buscas, sendo que em momento algum visualizou a descoberta dos narcóticos, razão pela qual somente tomou conhecimento da acusação de tráfico nesta delegacia. Que, ao responder aos PMs que não havia drogas no veículo, o militar, cuja identidade não sabe indicar, disse que “então passaria a haver”. Que desconhece as razões pelas quais a PM forjou o flagrante. Que trabalha como caixa de supermercado. Que nunca foi presa. Que está grávida de 5 meses.

Em audiência judicial, as provas orais foram produzidas e interrogados os réus. Policiais ouvidos confirmaram, em síntese, o depoimento dado em solo policial. Em audiência em continuação, a testemunha Priscila Amorim disse que não estava presente, não viu a abordagem. Eles passaram em casa para levar a neta dela em casa e foram embora. Normalmente saem da sua residência e seguem pelo terminal para irem para a casa.

O Policial Casemiro disse que as drogas já haviam sido encontradas. A mulher estava exaltada, estava grávida. Solicitou apoio de uma policial feminina que fez a revista nela. Foi encontrado dinheiro e droga com ela, no sutiã. O réu teria confessado informalmente para os policiais presentes.

A testemunha Rosângela não teve conhecimento dos fatos. Não sabem do envolvimento com droga. O dinheiro era para pagar parcela de apartamento. Ela trabalha como cabelereira e manicure.

A testemunha Ricardo, policial militar, que quando chegou ao local dos fatos, já havia ocorrido a abordagem. Foi feito o apoio da viatura, chegando em seguida à abordagem. Os policiais detiveram a moça, um passageiro e ficaram na escolta da ré. A ré estava exaltada. A policial feminina foi chamada e fez a busca pessoal, encontrando dinheiro e drogas no sutiã da ré. O réu, segundo a testemunha, teria confessado os fatos informalmente.

A ré, após a qualificação, no seu interrogatório de mérito, narrou que o dinheiro estava no seu carro, fruto do seu trabalho. Explicou que era do serviço e tinha acabado de vender uma moto. O celular foi apreendido. Só viu as drogas na delegacia. Tinha acabado de sair de um serviço, estava grávida e fazia serviços de manicure e cabelereira. Juntou cerca de R\$ 1.700,00. O apartamento estava indo para leilão e precisava pagar a parcela do saldo devedor em aberto. O restante foi decorrente da venda de uma motocicleta. Estava indo abastecer e ir para a casa. Disse que a policial não encontrou droga com ela, só dinheiro que realmente era dela.

O réu narrou, em seu interrogatório, que não foram encontradas drogas com ele. Imediatamente parou seu automóvel quando os policiais o abordaram. Só viu a droga após a abordagem. O dinheiro da Kelly estava com ela. Não tinha droga dentro do carro. Os 3 mil reais da venda da moto pegou no sábado e o da Kelly também. Só o da sogra que deu um dia antes. Trabalha e não usa drogas.

A absolvição é medida que se impõe. Não há provas capazes a afirmar, estreme dúvidas, a dinâmica delitiva e a prática da conduta descrita na inicial. Não se trata de considerar a versão do acusado alheia às provas dos autos, mas a constatação da inexistência de prova diversa daquelas que embasaram o starter investigativo. Conceder peso menor à versão do acusado significa, em suma, atrair ônus probatório ao acusado, invertendo o estado de inocência (Por todos, Pacelli.

2020. P. 86 ; Aury Lopes, 2020, p. 143). Também o STF : “ AS ACUSAÇÕES PENAIAS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA . - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado.” HC 88.875/AM Rel. Min. Celso de Mello.; em sentido similar, o E. TJSP: “Firme negativa por parte do acusado. Apelação provida para absolver o acusado por insuficiência de provas.” (TJSP; Apelação nº. 1525685-32.2020.8.26.0228; Rel. Des. Amable Lopez Soto; 12ª Câmara de Direito Criminal; j. 15.12.2021).

Ante o alinhavado , desponta a absolvição ante a insuficiência do conjunto probatório o único desfecho possível. Ademais, o firme relato dos acusados, ainda na Delegacia, acerca de abusos cometidos por policiais demonstram que tais versões revestem-se de seriedade, bem como torna frágil a versão acusatória, arrimada exclusivamente na versão dos condutores do flagrante, cuja atuação é desdita pelos presos que narraram condutas despidas do véu da legalidade. Neste ponto é de se salientar que o reconhecimento de eventual conduta abusiva não requer apenas o laudo apontando lesões. Tal laudo se prestaria , tão somente, a apontar lesões, por óbvio, desconsiderando a gama de condutas abusivas que podem existir, como coações físicas (não geradoras de lesões), coações morais e psicológicas decorrentes de pequenos tapas e empurrões praticados por agentes das entidades de segurança estatal.

Subsidiariamente, a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, eis que preenchidos seus requisitos. Ambos são primários, nada há nos autos que demonstre que se dedique à atividade criminosa ou pertença à organização criminosa. Ademais, a mera quantidade de drogas não é hábil a, por si só, apontar dedicação à atividade criminosa e deve ser valorada na primeira fase. Assim: “o caso em que o agente, na qualidade de ?mula do tráfico?, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga ? ainda que em grandes quantidades ?, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva, situação, portanto, insuficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)” . Ademais, meros antecedentes infracionais não se revestem de argumentação idônea a obstar a aplicação da minorante. Assim: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214089 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022).

Quanto a dosimetria, requeiro seja fixada a pena no mínimo legal, anotando que a quantidade e diversidade de drogas não é anormal à espécie, bem como seja considerada a atenuante da confissão informal, em estrita obediência ao entendimento uniformizado pelo STJ sobre o tema por todos: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de

20/6/2022, e tal atenuante deve compensar com eventual reincidência (“Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.” (AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Aponto que não há relação da conduta do agente com o estado de pandemia declarado, razão pela qual tal agravante não deve incidir. Aplicado o art. 33, par. 4º da Lei 11.343/06, a fração de diminuição deve ser de 2/3, na terceira fase, sendo possível o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Caso não aplicada a minorante, pugno pelo regime inicial semiaberto em atenção à primariedade e o quantum de pena aplicado. . Inexistindo alterações nas circunstâncias que os mantiveram afastados do claustro cautelar, requeiro seja concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

WESLEY HENRIQUE AMORIM ZEFFA e KELLY FERNANDA FRANCA FAZOLIN, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso de pessoas (CP, art. 29), porque no dia 09 de maio de 2021, por volta de 00h54, na Rodovia do Açúcar, km 493, Jardim São Francisco, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, traziam consigo e transportavam, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 03 (três) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 0,7g (sete decigramas) (item 1, fls. 34/37), 17 (dezessete) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) (item 2, fls. 34/37), 21 (vinte e um) invólucros em papel alumínio contendo cocaína em forma de crack, com peso líquido de 3,5g (três gramas e cinco decigramas) (item 3, fls. 34/37), e 05 (cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., “maconha”, com peso líquido de 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) (item 4, fls. 34/37), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Wesley – que de longa data se dedica ao tráfico de drogas – e Kelly transportavam e traziam consigo porções de cocaína, crack e maconha no veículo VW/GOL, placas EAS 0287/Piracicaba/SP.

No início da madrugada, imprimindo alta velocidade ao ultrapassarem uma viatura policial, foram acompanhados e abordados por policiais militares.

Nas buscas, os agentes localizaram R\$ 2.210,50 (dois mil duzentos e dez reais e cinquenta centavos) no porta-luvas no veículo. No banco traseiro, dentro de uma caixa de óculos, 05 (cinco) porções de maconha, 21 (vinte e uma) de crack e 17 (dezessete) eppendorfs de cocaína.

Durante a diligência, Kelly foi revistada por policial feminina e, sob seu sutiã, localizados R\$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro reais) e outros 05 (cinco) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles encontrados no carro (vide fotos fls. 28/30).

Informalmente, Wesley confirmou que o dinheiro era produto do tráfico de drogas por eles praticado (fls. 04 e 05). Na delegacia, porém, ambos negaram os fatos (fls. 06/09).

Por ocasião da apresentação da ocorrência à autoridade policial, Kelly foi submetida a minuciosa revista pessoal e então encontrada, sob suas vestes íntimas, mais R\$230,00 (duzentos e trinta reais).

O exame pericial constatou a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto fls. 24/26 e laudo fls. 34/37).

A denúncia foi oferecida, sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 131/139), sendo determinada a notificação dos réus para oferecerem defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 154/155).

Os réus foram notificados (fls. 165 e 167) e apresentaram defesa prévia, na qual alegaram inocência (fls. 171/173).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência virtual (fls. 174/176). Os réus foram citados (fls. 192 e 196).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 199/201) e 04

testemunhas de defesa, sendo os réus interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada nos autos de exibição e apreensão de fls. 24/27, nas fotografias de fls. 28/32, no laudo de constatação de fls. 34/37, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 160/163, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu Wesley disse que, na data dos fatos, estava trafegando com seu automóvel na companhia de sua esposa, quando recebeu ordem de parada da Polícia Militar, que prontamente atendeu. Abordados, nada de ilícito foi encontrado consigo ou com sua esposa. Os policiais militares apenas encontraram uma certa quantia de dinheiro no console do seu automóvel. Não sabe precisar a quantia encontrada, sendo certo que lá havia pouco mais de R\$ 2.000,00, resultantes da venda de uma motocicleta de sua propriedade, ocorrida no mesmo dia, e mais algumas centenas de reais provenientes da venda de lingerie realizada pela sua esposa. Não havia drogas no automóvel, tampouco com a sua mulher. As drogas foram postas no veículo pelos próprios policiais militares. Durante a ação, foi separado de sua esposa e pressionado a confessar a prática do tráfico. Desconhece as razões pelas quais a Polícia Militar forjou o flagrante. Durante a ação policial, o Sgt. Casemiro lhe desferiu um soco no peito, do qual não resultou lesão. Estando com sua esposa na sala de espera da Delegacia de Polícia, o mesmo policial desferiu um soco no rosto da ré, não havendo quaisquer marcas ou resquícios de tal violência (fls. 06/07).

Em Juízo, o réu Wesley afirmou que não entendeu a questão da droga. o dinheiro reconhece. Quando deram ordem de parada, já parou imediatamente. Abriu a porta do carro e disse que estava com a família e tinha dinheiro no porta-luvas. Depois, apresentaram uma quantia de drogas. não tem nenhum conhecimento da droga. R\$ 3.000,00 eram provenientes de uma moto, que tinha vendido e passou para receber. R\$ 1.700,00 eram da ré, que tinham passado para receber das clientes. A mãe de Kelly também tinha dado R\$ 1.000,00 para pagarem o apartamento, que estava indo para leilão. No porta-luvas havia R\$ 4.000,00, R\$ 3.000,00 da moto e R\$ 1.000,00 da sogra. O restante do dinheiro estava com Kelly. Não havia droga dentro do carro. Não sabe o motivo da acusação. Pegou o dinheiro da moto às 21h00. O dinheiro que passou recolhendo de Kelly foi pego depois. Depois, passaram na sua mãe, ficaram um tempo lá e foram embora, por volta de 23h00. Não faz uso de drogas.

Na Delegacia de Polícia, a ré Kelly contou que, na data e horário dos fatos, estava com seu esposo, quando receberam ordem de parada da Polícia Militar, que foi prontamente por ele atendida. Abordados, nada de ilícito foi encontrado consigo ou com seu marido. Os PMs apenas encontraram uma certa quantia de dinheiro no porta-luvas do automóvel. Ela própria indicou aos militares a existência de tais valores. Não sabe precisar a quantia encontrada, sendo certo que lá havia pouco mais de R\$ 2.000,00 resultantes da venda de uma motocicleta pelo seu marido e, ainda, mais algumas centenas de reais provenientes de serviços de estética por ela realizados. Não trazia drogas consigo, tampouco havia entorpecentes no automóvel. As drogas foram postas no veículo pelos próprios policiais militares. Acompanhou as buscas e em momento algum visualizou a descoberta dos narcóticos, razão pela qual somente tomou conhecimento da acusação de tráfico na Delegacia. Ao responder aos PMs que não havia drogas no veículo, o militar, cuja identidade não sabe indicar, disse que "então passaria a haver". Desconhece as razões pelas quais a PM forjou o flagrante. Trabalha como caixa de supermercado. Nunca foi presa e está grávida de 05 meses. Na sala de espera da Delegacia de Polícia, o Sgt. Casemiro desferiu um soco em seu rosto, sem, contudo, deixar marcas ou lesões (fls. 08/09).

Judicialmente, a ré Kelly falou que realmente foi achada a quantia de dinheiro no

carro. Logo que saíram do bairro para entrar na pista, já pararam. Desceu e já avisou que havia dinheiro no porta-luvas do carro. O policial perguntava o motivo pelo qual andava com dinheiro no carro, numa hora daquela. Falou que era do seu trabalho e da venda da moto do seu marido. Os policiais falaram que eram de droga e foram falando até que chegou na Delegacia. Não havia nenhuma droga no carro. Seu marido não acompanhou a abordagem. O policial Carlos segurou-a pelo braço e falou que estava grávida, mas ele não acreditou. Uma policial feminina a revistou, porque seu marido pediu que guardasse o dinheiro. Na época, tinha acabado de sair do Savegnago e estava fazendo serviço de sobranceira. Tinha juntado pouco mais de R\$ 1.700,00 com o serviço de sobranceira. Seu marido tinha vendido uma moto, por R\$ 3.000,00. Iriam pagar o apartamento que estava indo para leilão. O réu passou com ela para receber o dinheiro da moto e também nas suas clientes, pelos cabelos, unhas e sobranceiras que tinha feito. Saíram da casa da sua mãe e estavam indo ao posto de combustível, quando foram abordados. Não faz uso de drogas. A policial feminina só encontrou dinheiro com ela. Na Delegacia, foi feita uma outra revista e encontraram mais R\$ 230,00 no bolso do seu macacão.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos. O policial militar Douglas Vitti esclareceu que estavam em patrulhamento pela rodovia, quando o Gol passou por eles em alta velocidade. Fizeram a ordem de parada e eles pararam. Quem dirigia o veículo era o réu. Eles desceram do veículo e, com o réu, nada havia. Dentro do veículo, em revista, encontrou no porta-luvas mais de R\$ 2.000,00 em dinheiro e atrás do banco do motorista, havia uma caixa de óculos com cocaína, maconha e crack. Uma policial feminina foi chamada e fez revista com na ré, com quem encontrou mais de R\$ 1.000,00 e 05 pinos de cocaína, embalados da mesma forma que aqueles que estavam na caixa de óculos. Indagado, o réu afirmou que o dinheiro era do tráfico de drogas, que ele estava fazendo "correria". Eles foram levados ao Plantão Polícia, quando a ré foi submetida a nova revista pessoal e, com ela, encontraram mais R\$ 230,00. Não conhecia os réus. A ré não falou nada sobre os fatos. Recorda-se que a droga da ré estava no sutiã, não sabendo onde estava o dinheiro. A ré falou que o dinheiro era proveniente de salão de cabeleireiro ou manicure. Os réus moram no Cecap. As viaturas estavam juntas, quando ocorreu a abordagem. Quem abordou foi a sua viatura. A outra viatura estava no apoio. O Padovani não participou, pelo que se recorda. Ninguém disse que conhecia os réus. O réu não era conhecido dos meios policiais. Não viu nenhuma discussão entre policiais e o réu (fls. 199/201).

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar José Carlos Seabra Júnior, segundo o qual estavam em patrulhamento, quando passou o veículo Gol em velocidade acima do limite, acharam suspeito e decidiram abordar. Deram sinais luminosos e o réu logo encostou. Vitti fez a busca pessoal e a busca veicular. Enquanto isso, fazia as consultas e pesquisas. Encontraram mais de R\$ 2.000,00 e drogas no carro. Em busca na ré, realizada por uma policial feminina, encontraram mais R\$ 1.000,00 e pinos de cocaína, que estavam no sutiã da ré. Indagados sobre o dinheiro, o réu acabou dizendo que o dinheiro era do tráfico. Na Delegacia, em nova busca na ré, encontraram mais dinheiro. A ré falou que o dinheiro do carro era fruto de seu trabalho. Depois que encontraram mais dinheiro, ela disse que não sabia de onde era. Não conhecia os réus. Não sabe se eles moravam em Piracicaba. Sua viatura abordou e o sargento Casemiro e o Cabo Zavaglia estavam no apoio. Padovani não estava na ocorrência (fls. 199/201).

Rosângela Aparecida de França admitiu que é mãe de Kelly. Disse que estava trabalhando à noite e ficou sabendo da abordagem no dia seguinte. Até o momento, não sabe de envolvimento dos réus com drogas. esse dinheiro era para a ré pagar parcela do apartamento que ela tinha negociado. A parcela era de R\$ 5.800,00. Ela entregou R\$ 1.000,00 à ré, R\$ 1.800,00 eram do trabalho da ré e R\$ 3.000,00 eram da venda de uma moto que o réu negociou. Entregou o dinheiro para a ré na sexta-feira e eles foram abordados na madrugada do sábado. Eles tinham vendido a moto há pouco tempo, para pagar o apartamento e não o perder. A ré fazia unha e cabelo, porque estava grávida. O réu fazia bicos.

Priscila Amorim Zeffa respondeu que é mãe de Wesley e sogra de Kelly. Não presenciou os fatos. Os réus passaram na sua casa, porque pediu que eles levassem a

neta para a sua casa. Depois disso, eles disseram que estavam indo para casa. não sabe se eles tinham dinheiro com eles, não ouviu dizerem nada. Morava no bairro Eldorado e os réus no Cecap. Eles costumam tomar o trajeto pelo Terminal e vão para casa. nunca viu a ré usando drogas. perto dela, o filho também não usava drogas. Nunca soube que eles vendessem drogas ou as transportasse.

O policial militar André Fabiano Casimiro afirmou que apoiaram a abordagem. Os policiais Seabra e Viti abordaram o veículo, onde se encontravam um casal. Após vistoria, os policiais encontraram drogas no veículo e dinheiro. Quando chegaram, os policiais estavam fazendo a vistoria e logo o avisaram. Também falando do dinheiro. Os policiais perguntaram sobre o dinheiro e ele disse não saber. A mulher estava bem alterada, dizia que era mulher, estava grávida, que ninguém colocava a mão nela, começou a falar o nome constante dos uniformes dos policiais. A partir disso, pediram apoio de uma policial feminina que foi ao local e revistou a ré, encontrando mais dinheiro e drogas. na Delegacia, a policial feminina fez uma revista íntima da ré, encontrando ainda mais dinheiro, nas vestes íntimas dela. No local, depois que a policial feminina ter encontrado droga e dinheiro no sutiã da ré, o marido dela falou que o dinheiro era do tráfico de drogas, que eles tinham feito a recolha. Não conhecia os policiais. Na Delegacia, os réus disseram que teria agredido a vítima e o réu, no local da abordagem, no entanto, isso não ocorreu, até porque nem teve muito contato com os réus.

O também policial militar Carlos Henrique Zavaglia relatou que teve uma ocorrência na região e uma viatura já estava lá. Sua viatura deslocou-se no apoio. Logo após a abordagem, chegaram no apoio. No veículo havia uma moça e um rapaz, na condução. Ficaram na escolta da moça e o rapaz acompanhou a revista do veículo. Na revista veicular, foi encontrado dinheiro e droga dentro de um porta óculos ou pochete. A moça estava totalmente alterada, dizia que estava gestante, que não poderia ser abordada. Ela falava que ninguém poderia por a mão nela, que iria fazer denúncia deles. Chamaram a policial feminina que acabou por encontrar no sutiã da ré, dinheiro e drogas. A ré não soube dizer quanto dinheiro havia. O réu acabou dizendo que estavam na recolha do dinheiro de droga. no veículo, havia mais dinheiro, que a ré falou que era proveniente do seu trabalho. Na Delegacia, a policial feminina fez revista íntima na ré. Soube que havia mais dinheiro com a ré. Nunca tinha visto os réus. Não houve qualquer agressão contra os réus.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Em solo policial, os réus negaram a existência de drogas com eles ou no interior do veículo. Quanto ao dinheiro, afirmaram que estava no consolo do veículo e era proveniente da venda de uma motocicleta (R\$ 2.000,00) e o restante da venda de lingerie (segundo Wesley) ou do serviço de estética (segundo Kelly).

Em audiência, o réu Wesley narrou que tinha dinheiro no veículo, mas não era proveniente do tráfico, mas sim da venda de uma moto, do trabalho de Kelly e emprestado da sogra. Negou que houvesse drogas no veículo.

Já Kelly descreveu que estavam saindo da casa da sogra e iam colocar combustível. Tinha ido pegar dinheiro da moto vendida pelo réu e de suas clientes. O dinheiro era proveniente dessa situação. Negou que houvesse drogas no veículo.

Os policiais militares esclareceram que estavam em patrulhamento, quando foram ultrapassados por um veículo em alta velocidade, o que despertou suspeita e, por isso, deram ordem de parada e foram de pronto obedecidos. Em busca pessoal, com Wesley, nada foi encontrado. Em busca veicular, localizaram R\$ 2.210,50 em notas diversas e, numa caixa de óculos, debaixo do banco do motorista, 05 porções de maconha, 21 pedras de crack e 17 pinos de cocaína. Kelly alegou que o dinheiro lhe pertenceria, mas não soube informar a sua origem nem a quantia existente. Ela foi submetida a busca pessoal e a policial feminina encontrou, em seu sutiã, mais R\$ 1.134,00 e 05 pinos de cocaína, idênticos àqueles encontrados no interior do automóvel. Questionado Wesley confessou que o dinheiro era oriundo do tráfico de drogas. Na Delegacia de Polícia, com a ré foram encontrados mais R\$ 230,00.

Os policiais militares arrolados como testemunhas de defesa narraram que foram no apoio da outra viatura, que abordou os réus. Quando chegaram, ficaram na contenção dos réus, enquanto os outros policiais revistaram o veículo e logo confirmaram o

encontro de droga e dinheiro. A ré estava exaltada e falava que não poderiam revistá-la, porque gestante. Uma policial feminina foi chamada e, em revista na ré, encontrou dinheiro e drogas em seu poder. O réu acabou dizendo que tinha feito a recolha do dinheiro do tráfico.

As testemunhas de defesa nada souberam dizer a respeito do fato que não presenciaram. Apenas a mãe de Kelly confirmou que tinha emprestado R\$ 1.000,00 à filha, para que pagasse parcelas atrasadas do apartamento.

Com efeito, existem duas versões sobre o mesmo fato: a dos réus, que negam a existência de droga no veículo, e a dos policiais, que alegam ter apreendido o entorpecente parte no interior do veículo e o restante na posse da ré Kelly. Resta saber qual versão merece credibilidade.

Os réus ultrapassaram a viatura em alta velocidade e isso provocou a abordagem. O depoimento dos policiais militares é unânime e firme no sentido da localização da droga em poder dos réus, nada havendo que afaste essa afirmação, já que nem conheciam os réus.

De outra banda, a fala dos policiais, tanto os arrolados na denúncia, quanto os arrolados na fase policial, encontra amparo nas drogas apreendidas.

Por outro lado, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial se amparados pelo restante da prova, como no caso dos autos. Ressalto que o depoimento dos policiais foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Ressalto que os policiais militares não conheciam os réus.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

“Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei” (TJRS – Ver. – Rel. Rubens Rebelo Magalhães – RJTJRS 74/11). No caso dos autos, os réus negam a existência de drogas. A prova dos autos foi suficiente para a certeza do consumo de terceiras pessoas. Vejamos. Os réus foram abordados em rodovia e, com eles, foi apreendida quantia considerável de droga, que não é comum ser encontrada com usuários (43 porções de cocaína e 05 porções de maconha). De outro lado, no veículo e com a ré, foram apreendidos R\$ 3.774,50 em